

1500569-92.2019.8.26.0540  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella  
Comarca: Mauá  
Foro: Foro de Mauá  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 05/10/2022  
... de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Mauá  
Foro de Mauá  
2ª Vara Criminal  
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500569-92.2019.8.26.0540 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500569-92.2019.8.26.0540  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
LEONARDO LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

LEONARDO LIMA DA SILVA foi denunciado por incursão no § 1º e nos incisos I, II e IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 20 de março de 2019, por volta de 00h15min, na Rua Santos Dumont, 526, Vila Bocaina, nesta cidade de Mauá, o denunciado, em unidade de designios com terceira pessoa ainda não identificada, subtraiu em proveito comum, durante o repouso noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em ferramenta de marca Makita e uma extensão elétrica, pertencentes a Pedro Rocha de Santana.

Recebida a denúncia, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 139).

Posteriormente, réu foi citado (fl. 191) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ou, ao menos, a fixação das penas nos patamares mínimos, reconhecendo-se a atenuante da confissão e afastando-se a causa de aumento do repouso noturno, sob regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.  
Decido.

Procede em parte a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-7), auto de exibição e apreensão (fl. 08), auto de reconhecimento de objeto (fl. 50), laudo pericial do local (fls. 63-6) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa e em juízo, o réu manifestou-se (fl. 04 e mídia digital).

A vítima, em solo policial, narrou não ter presenciado a subtração, mas confirmou que (sic) "equipamentos ficam guardados durante o período noturno em um almoxarifado no interior da obra com corrente e cadeado e quando chegaram para trabalhar na manhã da data dos fatos notaram o cadeado estourado e a falta dos objetos; Que já substituiu o cadeado e reconhece os objetos sem sombra de dúvidas como sendo os de sua propriedade" (fl. 48).

Os policiais militares, na fase inquisitiva, historiaram que (sic) "por volta das 00h15min, o COPOM irradiou uma ocorrência de furto a uma construção civil, segundo informações passadas via 190, dois indivíduos entraram no local e furtaram uma máquina do tipo Makita e alguma coisa em um saco branco e se evadiram do local; que se dirigiram ao local e passaram a patrulhar nas imediações, quando visualizaram dois indivíduos com um saco branco e um objeto nas mãos, ambos, ao visualizarem a viatura soltaram o saco e o objeto no chão, correram, um deles conseguiu fugir, mas o outro foi rapidamente abordado, logo à frente dos objetos, pois ele não conseguiu correr muito; que constatarem que dentro do saco branco havia uma extensão elétrica e o objeto se tratava de uma máquina de cortar pisos, azulejos e madeiras da marca Makita; que o indivíduo, qualificado como Leonardo Lima da Silva, RG 36.708.248, informalmente no local confessou que tinham acabado de furtar os objetos da construção civil para vender e conseguir trocar por drogas; que o muro da construção civil de onde eles furtaram os objetos, visualmente, tem aproximadamente dois metros e meio" (fls. 02-3).

Em juízo, o policial militar Rafael reiterou integralmente suas declarações. Informou que, em patrulhamento pelo local, visualizou o réu e um outro indivíduo portando sacolas e objetos. Ao visualizarem a viatura, os indivíduos dispensaram tais objetos para tentar fugir. Leonardo foi detido em flagrante na posse dos objetos furtados e admitiu a subtração mediante escalada do muro. Não se recorda de eventual rompimento de obstáculo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de

menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

As qualificadoras do concurso de agentes e da escalada restaram comprovadas pela prova oral colhida e pelo laudo pericial de fls. 63-6.

Por outro lado, necessário afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Inicialmente, convém destacar que a denúncia não descreve no que consistiu o rompimento de obstáculo, apenas mencionando que os objetos estariam trancados e fazendo menção à fl. 48 dos autos. Além disso, embora a vítima tenha noticiado o rompimento de um cadeado (fl. 48), tal informação não foi corroborada por outros elementos de prova, notadamente pelas declarações dos policiais e pelo laudo pericial do local.

Da mesma forma, não deve incidir a causa de aumento do repouso noturno, em virtude do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ, Tema Repetitivo 1087, REsp 1888756, REsp 1891007 e REsp 1890981).

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo manifestou-se:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO APLICAÇÃO AO FURTO QUALIFICADO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DO STJ. TEMA 1087/STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. Consoante novel entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, fixada por meio de precedente dotado de força vinculante, "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ, Terceira Seção, REsp. nos 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ - tema 1087). Impossibilidade de valorar, em recurso exclusivo da defesa, o repouso noturno como circunstância judicial negativa, sob pena de indevida reformatio in pejus. V. acórdão de fls. 267/288 reformado para, afastada a majorante do repouso noturno, redimensionar as penas do réu Leandro da Silva Almeida para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa mínimos, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II (escalada) e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal; mantidos, no mais, a r. sentença e o v. acórdão recorrido. (TJSP; Apelação Criminal 1500070-83.2020.8.26.0537; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022 - grifo nosso).

FURTO QUALIFICADO - Art. 155, §§ 1º e 4º, c.c. art. 14, II, CP - Apelos ministerial e defensivo já julgados - Trânsito em julgado para o órgão acusatório - Recurso Especial interposto pela defesa - Determinação pela C. Presidência da Seção Criminal deste E. TJSP de nova análise por esta Câmara - Juízo de retratação, cf. art. 1030, II, CPC - Tese firmada pelo E. STJ, no Tema Repetitivo nº 1087, de que 'A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime

de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)' - Necessidade de afastamento da majorante - Adequação da pena - Descabimento de análise dos demais pleitos por meio deste - Recurso defensivo parcialmente provido (voto nº 46429). (TJSP; Apelação Criminal 1501423-15.2020.8.26.0617; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022 - grifo nosso).

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo uso de chave falsa, majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Réu confesso. Prova segura. Qualificadora demonstrada pela prova oral e pericial. Condenação mantida. Dosimetria. Mantidos o aumento operado na primeira fase, pelos maus antecedentes e a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda etapa. Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno deve ser afastada. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.087 do STJ). Maus antecedentes e reincidência impõem o regime prisional fechado. Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1538267-79.2021.8.26.0050; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022 - grifo nosso).

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto duplamente qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, de rigor a condenação.

Passa-se à dosagem das penas.

Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão fl. 38 - proc. 274-37.2016), pela prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração - e diante da multiplicidade de qualificadoras, sendo que a escalada foi utilizada para qualificar o crime e o concurso de agentes para exasperar a reprimenda, perfazendo, 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa. Neste sentido:

"(...) O apelante foi beneficiado com a fixação da pena base no piso legal, haja vista a multiplicidade de qualificadoras, sendo que, uma delas poderia ter sido utilizada para qualificar o crime e, as demais, para exasperar a reprimenda básica". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500815-20.2021.8.26.0540, Rel. Des. FERNANDO SIMÃO, j. 16.03.22).

"APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL AMPARADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA QUALIFICAR O CRIME E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP DESFAVORÁVEIS - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - POSSIBILIDADE DEVIDO À REINCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. A confissão e a delação extrajudicial, amparadas nos depoimentos das testemunhas e nos demais elementos dos autos, formam prova robusta para condenação. Não caracteriza bis in idem a utilização de uma das qualificadoras para qualificar o crime do furto duplamente qualificado, e outra como circunstância judicial. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do artigo 59 do CP desfavoráveis, o que também justifica a fixação do regime fechado para cumprimento de pena, mormente se o réu é reincidente." (TJ-MS - APR: 10350 MS 2005.010350-7, Relator: Des. Carlos Stephanini, Data de Julgamento: 07/03/2006, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/03/2006). G.N.

"HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, possível que uma seja utilizada para caracterizar o tipo qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável. 2. No caso, incidiam as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de agentes, sendo que uma serviu para a tipificação do crime de furto qualificado e a outra como circunstância judicial desfavorável - motivo pelo qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -, não havendo qualquer constrangimento ilegal ocasionado ao paciente. 3. Ordem denegada." (STJ - HC: 202035 SP 2011/0070113-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/06/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2011). G.N.

Quanto à possibilidade de valorar a prática do crime durante o repouso noturno na primeira fase da dosimetria, manifestou-se o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1087:

"[...] é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto." (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022). G.N.

Ainda, sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"Admite-se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem". (STJ. REsp 1946490/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda fase, diante da reincidência específica (certidão de fls. 37-8 - proc. 5213-59.2013), a reprimenda sofre acréscimo de mais 1/3, atingindo 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

"Hipótese em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de ser o paciente reincidente específico, argumento que se alinha à jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes" (HC n. 348.170/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 2/5/2016 – grifo nosso).

"Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica" (HC n. 331.534/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 27/10/2015).

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014).

Ainda, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente específico. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Causa de aumento devidamente constatada. Regime fechado mantido. Recurso não provido. [...] Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e por ser o réu reincidente específico (fls. 115/116) as penas foram acrescidas de 1/3, perfazendo, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. [...] Assim, por não entender infundado o aumento da pena, ante as justificativas expostas na r. sentença, - réu reincidente - fica mantida a fração aplicada, como lançada. [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0004499-21.2021.8.26.0348; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022 – grifo nosso).

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, fugindo em poder da res furtiva, não tem o intuito de colaborar para a elucidação do ocorrido. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobeja seria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a

confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6). Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido:

PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decurso, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP;

Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO - SÚMULA 231, DO C. STJ. - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.n.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

"Agravos regimentais no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRg no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, "em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal", tendo o Magistrado pontuado que "a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação" (fl. 54). Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal" (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Define-se, assim, a condenação em 03 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa.

O valor do dia-multa será o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, frente à interação criminosa, por crimes da mesma natureza, inclusive. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta. Pela mesma razão, incabível a aplicação de outros benefícios.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LEONARDO LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 03 anos e 04 meses de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e 16 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão nos incisos II e IV do parágrafo 4.º do art. 155 do Código Penal.

Faculta-se o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 247).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella – Juiz de Direito  
(assinado eletronicamente)

Mauá, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA